

1500359-68.2021.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: CRISTINA ESCHER

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... Burgarelli negou envolvimento com o tráfico. Já havia reconhecido Fernando antes de Burgarelli indicar com quem estava. Afirma ter conhecimento de que Fernando é irmão de Rafinha, chefe do tráfico no bairro. Não conseguiram localizar o veículo mencionado. Ele foi localizado por uma equipe Rocam, que fez a abordagem e vistoria, mas nada de ilícito foi encontrado, nem em posse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

2ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500359-68.2021.8.26.0573 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500359-68.2021.8.26.0573

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2344083/2021 - DISE-DEL.SEC.BOTUCATU, 22015454 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 71/21/219 - DISE-DEL.SEC.BOTUCATU, 2344083 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno dos Santos Burgarelli e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

BRUNO DOS SANTOS BURGARELLI e FERNANDO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, em concurso material, porque, em data incerta, mas anterior ao dia 17 de dezembro de 2021, em horário e locais incertos, mas nesta Cidade e Comarca, associaram-se para o fim de traficarem drogas e no dia 17 de dezembro de 2021, por volta das 11h00, na Avenida Cláudio Ferreira Cesário, nesta cidade e comarca, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para a entrega ao consumo de terceiras pessoas, 03 (três) "tijolos" de cocaína em forma de "crack", pesando 3.122,08g, droga esta que determina dependência física ou psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O rito da Lei 11.343/06 foi convertido em ordinário, a denúncia foi recebida (fls. 117/120), os réus foram citados (fls. 181 e 183) e apresentaram resposta à acusação (fls. 186/187). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 188/189) e designada audiência de instrução. Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas e os réus interrogados.

Nos memoriais escritos (fls. 258/265), o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com condenação dos acusados em relação ao delito previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06 e a absolvição em relação ao delito do artigo 35, do mesmo diploma legal, ante a ausência de provas.

A defesa do acusado Bruno dos Santos (fls. 270/278), em sede de alegações finais, pleiteia pela absolvição do acusado nos termos do artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal, ou pela desclassificação da conduta para a infração penal prevista no artigo 28, caput, Lei 11.343/06. Em caso de condenação requer pela fixação da pena no mínimo e regime aberto de cumprimento, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa do acusado Fernando dos Santos (fls. 279/288), por sua vez, requereu sua absolvição nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Não há preliminares ou prejudiciais ao mérito a serem analisadas. No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Ante a acurada análise dos autos, tem-se que procede a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, vez que a materialidade dos delitos veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 01/03), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06), pelo laudo de constatação provisória (fls. 22/24), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 101/103) e prova oral produzida.

A autoria em relação ao tráfico de drogas está, igualmente, caracterizada.

A testemunha da acusação, Rodrigo Ferreira da Silva, policial militar, relatou que receberam uma denúncia, informando que um veículo GM/Corsa iria até o bairro Monte Mor para efetuar uma entrega de drogas. A denúncia trazia, inclusive, a placa do veículo, mas não informava quem era o indivíduo que o dirigia. Fizeram uma consulta pelo projeto Radar em relação ao veículo, confirmando que este havia saído de manhã de São Paulo em direção ao interior do estado. Decidiram realizar patrulha no bairro para localizar o veículo, mas não conseguiram num primeiro momento.

Posteriormente, entraram em uma estrada de terra que margeia o bairro. A certa altura, do lado direito, localizaram o réu Fernando, vulgo Jacaré, muito conhecido no tráfico de drogas. Já o haviam abordado em outras ocasiões. Ele estava em pé, com uma sacola na mão e mais um outro indivíduo com ele, agachado. Avistando a viatura, Fernando largou a sacola e correu, assim como o outro indivíduo. Fernando conseguiu se evadir nesse dia. Contudo, conseguiram abordar Burgarelli. Fizeram busca pessoal, mas nada foi localizado. Retornaram ao local onde os dois estavam anteriormente e localizaram ali uma sacola no chão, contendo 3 tijolos de crack. Indagado, Burgarelli confirmou que estava ali em companhia de Fernando, a quem pertencia a droga, e que estava ali apenas para experimentar a droga, para saber se era droga de qualidade, a pedido de Fernando. Burgarelli negou envolvimento com o tráfico. Já havia reconhecido Fernando antes de Burgarelli indicar com quem estava. Afirma ter conhecimento de que Fernando é irmão de Rafinha, chefe do tráfico no bairro. Não conseguiram localizar o veículo mencionado. Ele foi localizado por uma equipe Rocam, que fez a abordagem e vistoria, mas nada de ilícito foi encontrado, nem em posse do motorista, que foi liberado. Não sabe se foi esse veículo que trouxe a droga ou mesmo se essa droga teria sido entregue em outro ponto.

Burgarelli apenas disse, quando abordado, que estava com o irmão de Rafinha, vulgo Jacaré, confirmando o que tinha visto. Não se lembra detalhes das vestimentas de Fernando. Nos dias seguintes aos fatos, fez patrulhamento no bairro, tentando localizar Fernando. Não o abordou depois desse episódio. Afirma que Burgarelli estava agachado, como que mexendo no mato, mas não havia terra remexida no local. Toda a droga apreendida estava dentro da sacola. Foi Bruno que informou, quando abordado, que havia drogas na sacola.

A testemunha arrolada pela acusação David Aparecido Zorzato Júnior, policial militar, corroborou o depoimento do colega, acrescentando que não conhecia os réus, pois trabalha em Botucatu há apenas dois anos. Assim, não os identificou antes da abordagem. O Sargento Rodrigo já conhecia o réu Fernando e o identificou de plano. Desembarcando da viatura ele já disse que se tratava de "Jacaré". A denúncia não dizia o local exato da entrega da droga. Ambos os policiais foram no encalço de Burgarelli.

A testemunha arrolada pela defesa de Fernando, Marcos André de Oliveira, relatou que Fernando era seu funcionário. Afirma que ele trabalhava de segunda a sexta-feira e não tem lembrança de que ele tenha perdido dias de trabalho. Soube que ele tinha sido preso através da esposa dele.

A testemunha arrolada pela defesa de Fernando, Jhenifer Meg de Lima Ferreira, informou que é esposa do Fernando. Em um primeiro momento, não sabia o motivo da prisão de Fernando. Ele não faltava nenhum dia do trabalho. Acharam que ele havia sido preso em razão de não estar assinando a carteirinha. Em nenhum momento os policiais foram até sua casa. Fernando foi abordado na véspera de Natal. Teriam verificado que estava tudo certo e ele foi liberado. Estavam na casa de sua sogra, quando guardas civis chegaram para prender Fernando, em razão de ordem judicial, mas sem dizer o motivo. Não recebia pessoas em sua casa que denotassem que ele estava envolvido com tráfico.

O acusado Bruno dos Santos Burgarelli, inquirido na esfera administrativa, negou que estivesse traficando drogas, aduzindo que era usuário. Em Juízo, admitiu parcialmente os fatos imputados. Informou que não conhece os policiais que efetuaram sua prisão e que é usuário de crack. Relata que ganhou uma quantia de drogas para usar e para guardar para uma pessoa que não quer identificar. No dia que o prenderam ele estava na casa de um amigo, bebendo e usando a droga. Comentou esse amigo que tinha a droga guardada na casa dos pais, onde estava morando à época. Pegou essa droga e a levou até um pasto, que é do lado de sua casa. Falou para o amigo ficar esperando na beira da cerca, desceu, se agachou para abrir o primeiro quilo, porque ia pegar um pedaço de cada quilo para o dono da droga não perceber que tinha mexido na droga dele. Nesse momento, ouviu o barulho de um carro. Levantou para ver que carro era, mas não viu mais seu amigo ali. Viu que era um carro normal, preto. Achou estranho seu amigo não estar mais ali. Abaixou para pegar a droga e viu o policial subindo o barranco. Saiu correndo até uma mata para baixo do pasto. Escondeu-se no meio do mato, mas o policial o encontrou e o agrediu, perguntando de quem era a droga. Respondeu que a droga não era sua, que era usuário. Foi algemado e levado até a delegacia. Em frente à delegacia, o policial perguntou novamente de quem era a droga. Confirmou que não era sua e que era usuário. O policial lhe falou que ia fazer um combinado com ele: que se confirmasse as perguntas que o delegado iria lhe fazer, seria liberado, por ser usuário. Disse, então, que iria confirmar. O delegado lhe perguntou se ele tinha ido a uma biqueira comprar crack e sido convidado por Jacaré para experimentar a droga. Respondeu que era assim que tinha acontecido. Respondeu também ao delegado que não o conhecia e não tinha mais informações sobre ele. Confirmou ao delegado que a droga não era sua e que era usuário. Afirma não conhecer Jacaré. O amigo com quem estava no pasto não era o Fernando. Não viu Fernando na delegacia. Apenas o encontrou no momento da audiência.

O acusado Fernando dos Santos Silva Júnior, não foi ouvido em solo policial. Em Juízo negou os fatos a si imputados delitiva. Não conhece os policiais que o prenderam. Estava trabalhando na época em que foi preso. Não conhecia o Bruno. É usuário de drogas. Foi preso quando estava na casa de sua mãe, acreditando que seria em razão de não estar assinando carteirinha. Já tinha sido abordado em frente à casa de sua mãe na véspera de Natal, mas não constava nada e foi liberado. Foi abordado no dia 30 de janeiro e o levaram para a delegacia. Nega os fatos. Diz que a família sofre perseguição da polícia em razão de fatos envolvendo seu irmão, que aconteceram em 2010. Sua cela não tem acesso à de Bruno.

Diante do contexto probatório formado no curso da instrução criminal, a condenação é de rigor, pois a conduta criminosa, relativa ao exercício do tráfico de drogas, imputada aos acusados restou cabalmente provada.

O relato das testemunhas, sob a égide do contraditório e ampla defesa, prestados com detalhes e de forma harmoniosa, são bastante convincentes e indicam a ocorrência da apreensão da droga e traficância descritas na denúncia. Em que pese as alegações do acusado Fernando de que haveria uma situação de perseguição dos policiais em relação a si, por conta de seu irmão, esta não restou comprovada. Pelo contrário, o reconhecimento do acusado foi efetuado por ambas as testemunhas, e confirmado sob a égide do contraditório e ampla defesa. Ademais, não se logrou demonstrar que as autoridades policiais, ouvidas sob o crivo do contraditório, eventualmente foram parciais, ou nutriram interesse em prejudicar o acusado, de modo que os seus testemunhos se mostram imaculados e, por isso, constituem meio idôneo de prova.

A versão dos réus é isolada do contexto probatório, sendo, inclusive, incoerentes entre si, o que se reputa tão somente à sua ampla defesa e ausência de compromisso com a verdade. Cumpre destacar que houve, por parte do acusado, Bruno dos Santos, confissão parcial em relação aos fatos a ele imputados. Como já analisado, a quantidade de drogas é expressiva, especialmente em se considerando a natureza da droga "crack", bastante agressiva. Some-se a isso a forma de acondicionamento dos entorpecentes, em tijolos, para posterior separação e venda. Não se vislumbra, portanto, das circunstâncias que a droga seria destinada ao consumo pessoal, mas sim ao comércio ilícito. Destaca-se, ainda, que a ausência de visualização de atos de mercancia não afasta a ocorrência do tráfico, pois a simples ação de guardar e ter em depósito os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido: Apelação- Tráfico de drogas- Condenação- Recurso defensivo -Pedidos de absolvição por falta de provas e de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal- Não acolhimento- Materialidade e autoria comprovadas -Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade- Prova oral harmônica e coesa. Apelante que transportava droga perniciosa (cocaína), em quantidade elevada (25,6 gramas de massa líquida -suficientes para produzir cerca de 100 porções individuais) e acondicionada em embalagem típica de mercancia- Circunstâncias da prisão que reforçam o "animus" de traficância- Tentativa de fuga do agente ao perceber a presença da viatura. Versão do sentenciado inverossímil e dissociada das provas coligidas. Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o ato de mercancia - Crime de ação múltipla ou conteúdo variado- Bastante comum a figura do "traficante-usuário" ou "usuário-traficante"- Pedido de aplicação da pena no mínimo legal- Acolhimento parcial- Desproporcional a exasperação da pena-base na fração de 2/5, a despeito da quantidade de droga - Redução para 1/6- Parecer favorável da douta Procuradoria de Justiça- Na segunda fase da dosimetria, o incremento em 1/3 teve fundamento idôneo - Reincidência específica- Precedentes- Revisadas as penas definitivas. Manutenção do regime inicial fechado- Recurso parcialmente provido (TJSP - Apelação Criminal 1500148-22.2018.8.26.0578, Relator(a): Juscelino Batista, Comarca: Ourinhos, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 09/03/2021, Data de publicação:09/03/2021).

Por fim, o depoimento das testemunhas de defesa nada acrescentaram que pudesse favorecer os acusados, pois sequer presenciaram os fatos. Com efeito, diante de todo o conjunto probatório, suficiente concluir que a droga descrita na denúncia pertencia aos réus e eram, sem sombra de dúvida, destinada à traficância. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, pois nada impede que o traficante seja, ao mesmo tempo, usuário dos entorpecentes. Desta maneira, resta nitidamente demonstrada a culpabilidade dos agentes no delito de tráfico de drogas, sendo de rigor a condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Contudo, em relação ao delito de associação para o tráfico, o conjunto probatório

não foi suficiente para demonstrar associação estável e duradoura entre os acusados para a prática da traficância, tratando-se a conduta, portanto, de mero concurso entre pessoas. Assim, não há provas suficientes, colhidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A dúvida razoável, na lição de Renato Brasileiro (in Manual de Processo Penal, 2021, p. 563), é a dúvida baseada na razão e no senso comum, é a dúvida que uma pessoa razoável possui, após sopesar as provas, que a leva a hesitar a tomar uma decisão. Não é especulação ou suspeita, não é compaixão.

No caso em apreço a análise dos elementos probatórios não convence para além dos limites exigidos de qualquer dúvida razoável quanto a materialidade e autoria. Aplicável, portanto, o in dubio pro reo, sendo a absolvição quanto a este fato típico medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

- réu Bruno dos Santos Burgarelli

Atendendo aos critérios norteadores dos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, em primeira fase verifico que o acusado não possui antecedentes (fls. 158) de fixação da pena, aplico-lhe a pena no mínimo, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição. Em sendo o acusado primário, tendo bons antecedentes, e não se dedicando a atividades criminosas, nem sendo integrante de organização criminosa, poderá ou não fazer jus à redução da sua pena de um sexto a dois terços, conforme as circunstâncias do caso concreto. Aqui, entendo que o julgador deve socorrer-se, ainda, dos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal e das peculiaridades do caso concreto, quer para verificar a viabilidade da aplicação do redutor da pena, quer para aplicar a redução mais adequada à hipótese.

Assim, é imprescindível, para a perfeita individualização das penas, e para evitar-se a eterna banalização das penas mínimas, que certamente não corresponde ao intuito do legislador nem aos anseios sociais, menos ainda à justa aplicação da lei ao caso concreto, analisar criteriosamente, além das condições previstas no parágrafo 4º do artigo 33, também as circunstâncias e consequências do crime, a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente, e os motivos que o levaram à prática da infração.

No caso dos autos, não há uma hipótese de extrema excepcionalidade a autorizar a redução diante da quantidade de droga apreendida e da agressividade de sua natureza. Dessa forma, na terceira fase, justifico a ausência de aplicação da redução de pena nos moldes do artigo art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

-réu Fernando dos Santos Silva Júnior.

Atendendo aos critérios norteadores dos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, em primeira fase verifico que o acusado não possui antecedentes (fls. 159/161) de fixação da pena, aplico-lhe a pena no mínimo, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, pela reincidência (fls. 159/161), aumento a pena em 1/3, fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição. Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei de Drogas, considerando a reincidência do réu.

Tendo em vista a natureza hedionda do delito de tráfico de entorpecente, o regime inicial de cumprimento das penas fixadas será o FECHADO. Sobre a pertinência da fixação de referido regime de cumprimento de pena, trago o seguinte precedente: "Por fim, mantenho o regime inicial fechado para início do desconto da corporal, sendo o único compatível com o delito, dada a determinação legal em se tratando de crime hediondo (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90). Cumpre observar que o ilícito do qual ora se trata, equiparado a hediondo, tem como principal engrenagem motora a

dependência química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício. Daí o reconhecimento da alta periculosidade da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado permitirá aos réus uma maior recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto social e a gravidade de sua conduta." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, AP 0002479-41.2010, Rel. Edison Brandão, j. 02/07/2013).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como inviável a concessão do "sursis", por não serem socialmente indicáveis, bem como porque o quantum da pena aplicada desautoriza o benefício.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial para:

A) CONDENAR o réu BRUNO DOS SANTOS BURGARELLI como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal.

B) CONDENAR o réu FERNANDO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 666 dias-multa, no valor mínimo legal.

C) ABSOLVER BRUNO DOS SANTOS BURGARELLI e FERNANDO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386 inciso VII do CPP.

Os réus, diante da necessidade da prisão cautelar durante todo o processo e desta condenação que a ratifica, não poderão apelar em liberdade, pois reputo que continuam presentes os requisitos da prisão preventiva. Recomende-se-os na prisão em que se encontram, com as cautelas de praxe.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, bem como dos objetos relacionados no auto de exibição e apreensão, pois são instrumentos, produtos ou proveito do crime em apreço. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Honorários proporcionais.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Botucatu, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA